

刑法
No243

R5-6

(配点：4)

月 日

月 日

性的自由に対する罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 不同意わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いて相手方の反抗を著しく困難にしてわいせつな行為をした場合に成立するから、不意をついて相手方の陰部に触れた場合には、同罪が成立することはない。(改)
- イ. 不同意性交の目的で、相手方の顔面を数回殴る暴行を加え、同人に鼻骨骨折の傷害を負わせたが、そのまま同人に逃げられたため、性交するに至らなかった場合には、不同意性交等未遂罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合となるのであり、不同意性交等致傷罪は成立しない。(改)
- ウ. 13歳の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合には、暴行又は脅迫を用いた場合でなくとも監護者わいせつ罪が成立する。
- エ. 不同意わいせつ罪は、被害者の名誉等を保護する観点から親告罪とされているから、告訴がなければ公訴を提起できない。(改)
- オ. 不同意性交の目的で、殺意をもって、強度の暴行を加えた上で相手方と性交し、同暴行により、同人を死亡させた場合には、不同意性交等致死罪のみが成立する。(改)

*本問は、試験実施直前の法改正を反映していなかったため、受験生全員が正答と取り扱われた。また、令和5年7月13日に施行された改正刑法を前提に、問題文中の「強制わいせつ」を「不同意わいせつ」に、「強姦性交」を「不同意性交」にそれぞれ読み替え、改題した。

No243

性的自由に対する罪

正答率

R5-6

正解

ア 2

イ 2

ウ 1

エ 2

オ 2

100%

ア 誤っている

176 条 1 項 5 号。同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態で、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者については、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立する。このような「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」には、不意打ちによるわいせつな行為が含まれていると解されるところ、不意について相手方の陰部に触れた場合には、不同意わいせつ罪が成立する。なお、改正前刑法では、本記述のような事案において、暴行・脅迫が強制わいせつ罪（改正前刑法 176 条）の構成要件になっており、その成否が問題となっていたが、不意について相手方の陰部に触れたような場合については、暴行自体がわいせつな行為に該当し、被害者の隙をついたような場合には、強制わいせつ罪の手段としての暴行に当たるとして強制わいせつ罪の成立を認めていた（大判昭 8.9.11 参照）。

イ 誤っている

181 条 2 項、177 条 1 項、最決昭 43.9.17。不同意性交等罪の罪又はこれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に、不同意性交等致死傷罪が成立する。「これらの未遂罪を犯し」という規定の文言から明らかなように基本犯である不同意性交等罪が未遂に終わっても死傷の結果が発生する限り本罪は既遂となる。さらに、不同意性交等致死傷罪が成立するには、基本犯である不同意性交等罪又はその未遂罪を犯したことで死傷の結果との間に因果関係がなければならない。そして、最決昭 43.9.17 は、死傷の結果は、性交等の行為自体から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でもよいとする。本記述では、不同意性交の目的で、相手方の顔を数回殴る暴行を加え、同人に鼻骨骨折の傷害を負わせており、不同意性交等罪の手段である暴行（177 条 1 項、176 条 1 項 1 号）によって傷害の結果が生じているため、不同意性交等致死傷罪が成立する。

ウ 正しい

179 条 1 項、176 条 1 項。18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、176 条 1 項の例による。本記述にあるように、13 歳の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合であれば、暴行又は脅迫を用いた場合でなくとも監護者わいせつ罪は成立する。

エ 誤っている

旧刑法下においては、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪など一部の性犯罪は被害者の名誉保護のために、刑事裁判にかけるか否かを被害者の意思にかからしめるために親告罪とされていた。しかし、近年、性犯罪によって肉体的・精神的に多大な被害を負った被害者にとっては告訴をするか否かの選択を迫られているように感じられたり、告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかという不安を持つ場合があるなど、親告罪であることによってかえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくないことが指摘され、このような実情に鑑み、現在の刑法では非親告罪とされている。

オ 誤っている

最判昭 31.10.25 は、殺意をもって、強度の暴行を加えた上で相手方と性交し、同暴行により、同人を死亡させたような場合について、不同意性交等致死罪（181 条 2 項）と殺人罪（199 条）が成立し、観念的競合（54 条 1 項）となるとしている。